

1500339-02.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255254/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20336837 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5325/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2255254 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500339-02.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255254/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20336837 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5325/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2255254 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDSON APARECIDO SOARES JUNIOR e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

ALEXSANDRO VICENTE e EDSON APARECIDO SOARES JUNIOR, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com o artigo 29 do Código Penal.

Notificados (fls. 380 e 382), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 377/378 e 386/391).

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 392/393) e os acusados

foram citados (fls. 437/438).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus (fls. 446/447).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

As defesas requereram a absolvição dos réus. Alexsandro pleiteou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima legalmente cominada (fls. 440/445 e 446/447).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/20), boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), fotografias (fls. 27/29 e 38/42), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 170/174), laudo pericial (fls. 175/293) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, o réu Alexsandro negou os fatos e aduziu, em síntese, que tinha ido a Jaú para comer esfihas com Edson, Tainara e a filha do casal. No caminho, seu irmão W. ligou para Edson, disse que estava perdido em Jaú, então foram busca-lo. Em seguida foram abordados e os policiais encontraram a droga dentro do veículo, cuja propriedade foi assumida pelo seu irmão. Ninguém sabia da existência da droga. Não fez qualquer menção de dispensar algo ao avistar a viatura. Seu celular foi verificado pelo Ilmo. Delegado e lhe foi devolvido, enquanto os aparelhos de Edson e W. restaram apreendidos. Já tinha sido preso por tráfico e era constantemente abordado por policiais militares.

Edson também negou o crime, confirmou a versão apresentada pelo corréu de que tinham ido a Jaú para comer esfiha, mas, ao contrário deste, afirmou que a ligação do menor W. foi para Alexsandro.

Os policiais militares Rodrigo e Marcos relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo Gol e perceberam que os acusados – o motorista Edson e o passageiro Alexsandro – demonstraram nervosismo e este fez menção de que iria dispensar algo, todavia recuou ao ser anunciada a abordagem. No veículo estavam, ainda, o adolescente W., sentado no banco traseiro ao lado de seu irmão Alexsandro, a esposa de Edson e uma criança. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No assoalho do assento ocupado por Alexsandro foi localizado um tablete grande e outras porções menores de maconha. Alexsandro aduziu que a droga pertencia a ele e ao irmão e que iriam fracioná-la para revenda. Edson afirmou que foi contratado pelos irmãos e receberia R\$ 50,00 em entorpecente pelo transporte da droga. Conheciam os acusados de outras abordagens e nunca tiveram nenhum problema com eles.

O adolescente W. avocou a propriedade da droga e disse que a adquirira na rodoviária de Jaú pelo montante de R\$ 1.800,00, proveniente de seu salário, para revenda. Após adquirir o entorpecente, pegou o ônibus errado e acabou descendo em um local desconhecido, pelo que ligou para Edson e pediu que ele fosse busca-lo. Não contou a Edson ou aos demais ocupantes do carro sobre a droga. Não disse aos policiais que iria comercializar a droga com seu irmão Alexsandro nem que pagaria Edson pelo transporte, desconhecendo a razão pela qual eles pudessem ter feito declarações nesse sentido.

Sindy, irmã de Aleksandro, afirmou que o adolescente assumiu a propriedade da droga e declarou que os réus não sabiam da existência do entorpecente. Aleksandro foi anteriormente preso por tráfico e, depois de solto, não mais praticou o comércio espúrio. Ele tinha trabalho lícito, mas era alvo de constantes abordagens policiais.

Tainara, esposa de Edson, asseverou que foi a Jaú com ele, sua filha e Aleksandro - seu vizinho - para comer. Quando já estavam em Jaú, W. ligou para Aleksandro, falou que estava perdido em Jaú e pediu para buscá-lo, sem ter ciência de que o irmão estava no carro de Edson. Edson não receberia nada pela carona. Não tinham conhecimento de que o adolescente estava com o entorpecente.

Talita, cunhada de Edson, narrou que no dia dos fatos a sua irmã e os corréus lhe convidaram para ir a Jaú comer, mas não pôde ir. Aduziu que Edson sempre foi trabalhador e o casal nunca esteve envolvido com o tráfico.

Pois bem.

As provas são suficientes para segura comprovação do crime narrado na denúncia.

Os réus negaram a traficância e, em suma, imputaram a W., irmão adolescente de Aleksandro, a propriedade exclusiva da droga. Tal versão, no entanto, foi infirmada pelo conjunto probatório.

Além da versão apresentada por W. para justificar sua presença no carro após suposta compra da droga ser inverossímil, não é demais destacar que os réus apresentaram relatos divergentes em juízo quanto ao destinatário da ligação que teria sido efetuada pelo referido adolescente e que tampouco foi comprovada.

A tal inconsistência devem ser somadas as contrariedades das versões colhidas em solo policial, oportunidade em que os réus (acompanhados de advogados) e Tainara apresentaram depoimentos conflitantes quanto ao encontro com Aleksandro e ao motivo pelo qual lhe deram carona.

Das fotografias de fls. 27/29 extrai-se que a significativa quantidade de maconha, droga com forte odor, não poderia facilmente ser ocultada nas vestes do adolescente sem que ninguém percebesse.

De outro lado, os policiais militares descreveram minuciosamente a abordagem, salientando que ambos os acusados demonstraram nervosismo e que o entorpecente estava no assoalho do assento ocupado por Aleksandro. Eles também afirmaram que Aleksandro e seu irmão admitiram informalmente o comércio espúrio e que Edson aduziu que receberia uma porção equivalente ao valor de R\$ 50,00 para fazer o transporte.

No mais, não foi comprovado motivo plausível que justificasse a falsa incriminação por parte das testemunhas de acusação, limitando-se Aleksandro a alegar perseguição da polícia em virtude de sua anterior prisão por tráfico.

Não há dúvida, nesse contexto, a tentativa dos acusados em atribuir ao menor a responsabilidade pela posse e transporte da maconha, a fim de se escusarem da reprimenda criminal.

A destinação para entrega a terceiros restou demonstrada pela expressiva quantidade de maconha apreendida, em conformidade com o restante da prova.

Assim, não há como acolher as teses defensivas, pois restou suficientemente comprovada a prática, pelos acusados, do crime narrado da denúncia.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que as penas-base devem ser majoradas considerando a elevada quantidade de entorpecente apreendida, apesar do seu menor potencial lesivo, se comparado a outras drogas. Assim, fixo as penas-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, majoro as penas de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o delito foi perpetrado com conluio com o adolescente W., aumento as penas de 1/6 para cada um dos acusados, perfazendo 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa.

Os réus são tecnicamente primários e sem antecedentes, pelo que aplico o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que eles se dedicassem a tal atividade criminosa por tempo considerável ou integrassem organização criminosa. Assim, diminuo cada pena de 2/3, tornando-as definitivamente em 2 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão e 264 dias-multa.

Considerando a pena aplicada e a primariedade dos réus, fixo, excepcionalmente, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Todavia, é incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na Lei nº 8.072/90, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelos motivos esposados na primeira fase.

As penas pecuniárias devem ser fixadas no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada pelos acusados.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial

e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incursos no artigo 33, § 4º c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. com o artigo 29 do Código Penal, os acusados ALEXSANDRO VICENTE e EDSON APARECIDO SOARES JUNIOR, qualificados nos autos, à pena de 2 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 264 dias-multa, no mínimo legal.

Excepcionalmente, faculto o apelo em liberdade. Expeçam-se, pois, alvarás de soltura clausulados.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do veículo Gol - usado para a perpetração do delito - e dos demais objetos apreendidos.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA